

1502040-62.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... pode ser utilizada como fundamento para afastamento do tráfico privilegiado, porquanto isso denota que o réu se dedica a atividades criminosas.

Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502040-62.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502040-62.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328387/2021 - DEL.POL.LEME, 21737779 - DEL.POL.LEME, 6634/21/807 - DEL.POL.LEME, 2328387 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA e outro

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

Vistos.

ALEXANDRE ANTONIO DA COSTA e JULIANO FERREIRA MARTINS foram denunciados por que (i) no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 14:30 horas, na Rua Alfredo Benedito Nogueira, n. 976, Jardim Carolina, neste Município de Leme, trariam consigo e guardariam, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de maconha, pesando aproximadamente 248 gramas, 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 0,4 gramas, 02 (duas) porções de cocaína, pesando aproximadamente 1 grama e 28 (vinte e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 16,2 gramas, drogas ilícitas¹, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (ii) em data anterior ao dia 02 de dezembro de 2021, e na mesma data, teriam se associado para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Os réus foram notificados (fls. 137) e apresentaram defesa prévia (fls. 112/113). A denúncia foi recebida (fls. 147/148).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação. A Defesa dos réus requereu a absolvição pela insuficiência de provas, e no caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há nulidade ou prova ilícita em razão do ingresso no domicílio do(a) acusado(a) sem prévio mando judicial.

O ingresso na residência de qualquer indivíduo, a despeito de sua natureza inviolável, é excepcionada em casos como o dos autos, onde haja a prática de crime e a consequente situação flagrancial, conforme expressamente prevê a Constituição em seu artigo 5º, inciso XI.

Isso porque, o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, cuja ação se protraí no tempo, permitindo a prisão do agente enquanto se mantiver este estado.

Nesse cenário, a garantia fundamental do acusado deve ser flexibilizada em razão de não poder ser utilizada como escudo para a prática de atos ilícitos, em razão da aplicação da técnica de interpretação da cedência recíproca, uma vez colocados em confronto duas garantias de ordem constitucional: a inviolabilidade do domicílio do acusado e a proteção à segurança e saúde pública, bens jurídicos afetados por sua conduta.

O colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu a questão: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-

2016).

No caso em apreço, houve situação, anterior ao ingresso, que justificou a atuação dos policiais. Como demonstrado durante a instrução, já havia outras denúncias que apontavam os acusados como responsáveis por traficar drogas nas obras em que trabalhavam. Isso foi corroborado por outra ocorrência (boletim de fls. 55/57).

Assim, diante dos elementos informativos apurados pela Polícia, é evidente a possibilidade de que, no imóvel onde se deu a apreensão, de fato houvessem drogas destinadas ao comércio ilícito, a partir de nova denúncia recebeu pelos policiais, o que se comprovou, porque apreendidas drogas no imóvel.

De mais a mais, ambos os agentes públicos ouvidos confirmaram que tanto Alexandre, quanto o proprietário da obra, Diego, autorizaram a entrada na casa, inexistindo elementos que possam sinalizar que as testemunhas, ambos agentes públicos, tenham faltado com a verdade.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 30/34), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 35/37 e 38/50), laudo de constatação provisória (fls. 51/52), laudo químico-toxicológico (fls. 132/134), laudos periciais (fls. 141/143 e 144/146 e 163/165) e prova oral.

Em relação ao acusado Alexandre, a autoria do crime de tráfico de drogas é certa.

A testemunha Danilo Guiguer, policial civil, relatou que recebeu uma denúncia, via telefone, feita por uma pessoa que preferiu não se identificar, informando que dois pintores de residências estariam vendendo drogas e as entregando com uma motocicleta. Foi informado, ainda, que as drogas ficariam guardadas nos locais onde eles trabalhavam. Também foi informado o nome dos indivíduos, sendo esses já conhecidos nos meios policiais. Foi junto do GCM João para averiguar os fatos.

Seguiram para o endereço apontado pelo denunciante e avistaram uma casa em construção, com o portão aberto, uma motocicleta semelhante a indicada na denúncia, estacionada defronte, e o réu Alexandre próximo ao portão, no interior do terreno.

O réu foi abordado e perguntado se havia mais pessoas no local e ele respondeu que sim. Também estavam na casa o réu Juliano, o proprietário da casa e mais uma mulher. Em busca pessoal encontraram no bolso do proprietário da casa, uma porção de cocaína, com o réu Juliano encontraram duas porções idênticas, com o réu

Alexandre nada de ilícito foi. Indagados acerca das denúncias, o proprietário do imóvel negou qualquer envolvimento com o tráfico. O réu Alexandre afirmou que havia dado as drogas para o proprietário e para o réu Juliano. O réu Juliano nada disse.

Indagados se havia mais drogas na casa os réus disseram que não. Entretanto, ao verificarem algumas latas, entre os pertences dos réus, encontraram, dentro de um balde de pintura, nove porções grandes de maconha, vinte oito porções de cocaína, fracionadas da mesma forma que as drogas encontradas anteriormente, 84 saquinhos, iguais aos utilizados para fracionamento da cocaína, vazios, uma balança de precisão e um saco contendo um pó branco. Após a localização das drogas o réu Alexandre confessou a propriedade de toda a droga. Esclareceu que, quando chegaram, o portão estava aberto. O réu Alexandre estava no portão e autorizou o ingresso nos policiais. O proprietário da casa também autorizou.

No mesmo sentido o testemunho do guarda civil municipal João Carlos Cerbi Júnior.

A testemunha Diego Fernando Rosa discorreu que possui uma casa em fase final de reforma e contratou os réus para realizarem a pintura do local. Que já conhecia os réus anteriormente, mas não tinha uma relação mais próxima a eles. Que não tinha conhecimento de que os réus vendiam drogas ou que guardavam droga na sua construção. Que na data dos fatos data fariam um churrasco para comemorar a finalização da obra e convidou uma conhecida. Que é usuário de drogas e havia comprado uma porção em outro bairro para seu uso. Que a droga encontrada em seu poder não foi recebida dos réus, pois sequer sabia que eles possuíam drogas. Não viu as drogas apreendidas no local, somente depois que foram levada à Delegacia. Conhecia os réus apenas de vista e porque sabia que eles trabalhavam com pintura. Disse que os policiais bateram e o Alexandre foi atender.

O réu Alexandre confessou que traficava as drogas apreendidas, as quais eram apenas dele. Juliano não sabia das drogas. Vendia os entorpecentes próximo ao local. Nunca se associou com Juliano, pois o conhecia há apenas um mês. Nunca viu Juliano vender

drogas. Negou ter autorizado a entrada dos policiais, os quais chegaram o abordando.

O réu Juliano disse que não tinha conhecimento dos entorpecentes e nem sabia que Alexandre mantinha as drogas no local. Nunca viu balança de precisão no local, apesar de ter olhado o imóvel em razão do trabalho. Nunca foi abordado com Alexandre pela polícia. Não ouviu Alexandre ou Diego autorizarem a entrada dos policiais na residência.

No que tange ao acusado Alexandre, a prova é segura para condenação, sobretudo porque sua confissão veio amparada nos depoimentos dos agentes públicos ouvidos durante a instrução.

Sobre o depoimento dos policiais, é certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, como visto, inexiste dúvida sobre a traficância, confessada por Alexandre. Já no tocante à conduta do réu Juliano, de fato, observa-se que não há prova segura para condenação, porque os elementos de prova não permitem a afirmação de que ele estivesse, de fato, conluiado com o corréu para a prática do comércio ilícito. Tudo sinaliza que ele apenas estava a trabalho na obra onde se deu a apreensão dos entorpecentes, que eram de propriedade de Alexandre, conforme por ele próprio confirmado.

Nesse contexto, diante da falta de elementos seguros a respeito da traficância, impõe-se a absolvição.

Afasto o crime de associação criminosa previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, pois em momento algum foi evidenciado o animus associativo, relativo à finalidade de praticar, reiteradamente, o crime mencionado no artigo 33, caput, da mesma Lei, tampouco a permanência na societas criminis, a qual não se confunde com a mera coautoria.

Acrescento o entendimento dos Tribunais:

O crime consuma-se com a simples associação previamente organizada, de caráter estável e permanente, independentemente de qualquer outro fato que venha a ser cometido pelos agentes. Desde que a associação delituitosa, já caracterizada, alcança seu fim consistente na prática de crimes, lesa nova objetividade jurídica, possibilitando o concurso de delitos (STJ, REsp 3.943/SP, 5ª T., rel. Min. Flaquer

Scartezzini, . 26-9-1990, DJ 5-11-1990, JSTJ 20/45).

O delito previsto no art. 35, da nova lei, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique, na societas criminis, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria (TJMG – Ap. Crim. 1.0145.08.435450-8/001, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/03/2009).

É possível que os acusados tenham cometido tal crime, no entanto, as provas amealhadas aos autos não são suficientes para um decreto condenatório.

Reconhecida em parte a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, nada há que recomende a exasperação, fixando-se a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A diversidade e a quantidade da droga serão levadas em consideração na terceira fase de aplicação da pena, para evitar bis in idem. Nesse sentido: A controvérsia destes autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em recente julgamento realizado pelo Plenário, ocorrido em 19/12/2013, na análise dos HC 112.776/MS e HC 109.193/MS, ambos de relatoria do Min. Teori Zavaski. Naquela oportunidade, esta Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza o bis in idem, bem como autorizou a análise monocrática dos pedidos de habeas corpus que tratem sobre o tema. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder discricionário, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente a quantidade e a natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem (STF – RHC/MC nº 122.496/RS, Relator: Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 22/08/2014 – grifos meus).

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): a despeito da confissão de Alexandre, incide a súmula 231 do STJ.

Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, observa-se que Alexandre responde a outro processo por fato análogo (autos nº 1503490-40.2021.8.26.0318), circunstância que pode ser utilizada como fundamento para afastamento do tráfico privilegiado, porquanto isso denota que o réu se dedica a atividades criminosas.

Neste ponto, mister consignar que: Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28-4-2017. (STJ, AgRg no REsp 1.902.766/SP, 6ª T., rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23-2-2021, DJe de 26-2-2021). Nessa mesma linha de pensamento: STJ, AgRg no AREsp 1.020.529/BA, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 18-4-2017, DJe de 28-4-2017; STJ, AgRg no HC 627.087/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 9-2-2021, DJe de 11-2-2021; STJ, AgRg no HC 591.559/MG, 6ª T., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2-2-2021, DJe de 10-2-2021.

Além disso, não foi pequena a quantidade de droga apreendida na obra onde o acusado trabalhava (a qual era de sua propriedade), tendo em vista que cerca de um quarto de quilo de maconha estava ali guardado, além de outras porções de cocaína. Ou seja, havia variedade e quantidade de droga apta a afirmar que não se tratava de pequeno traficante, até porque já responde por outro fato parecido.

Conforme leciona Renato Marcão, a apreensão de expressiva quantidade de droga configura indicativo de que o agente é integrante de organização criminosa. A grande quantidade e variedade da droga, a propósito, atenta com maior intensidade

contra o bem jurídico tutelado, porquanto inegável a relevância de seu acentuado potencial lesivo, e faz desaconselhar o reconhecimento do "tráfico privilegiado". (Tóxicos. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 138).

E, no mesmo sentido, confirmam-se os seguintes julgados:

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (STJ, AgRg no HC 615.796/CE, 5ª T., rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20-10-2020, DJe de 22-10-2020).

Esta Corte tem reiterada orientação de que a quantidade e a natureza da droga, associadas ao contexto em que se deu a sua apreensão, podem evidenciar a dedicação à atividade criminosa (STJ, AgRg no HC 604.754/SP, 6ª T., rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22-9-2020, DJe de 28-9-2020).

Assim, não se reconhece a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Pena definitiva: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o semiaberto, considerando que se trata de agente tecnicamente primário e que confessou a prática do tráfico e levando-se em conta ainda o tempo de prisão provisória já cumprida até a soltura do acusado.

Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): incabível diante do quantum da pena.

Julgo procedente em parte a ação penal e: (i) absolvo Juliano Ferreira Martins, qualificado nos autos, de ter praticado os delitos previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) absolvo Alexandre Antonio da Costa, qualificado nos autos, de ter praticado o delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) condeno o acusado Alexandre Antonio da Costa, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo legal.

Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, inclusive a motocicleta, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD);

b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da

Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou

oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intimem-se.

Leme, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA